

1500070-18.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pela ré se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. - HC

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500070-18.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-18.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em
Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2001727/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 18/2022 -

DEL.POL.CUBATÃO, 2001727 - DEL.POL.CUBATÃO, 18/22/202 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSEANE BARBOSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ROSEANE BARBOSA DA SILVA foi denunciada e está sendo processada por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, na Rua Seis, próximo ao n.º 130, Cota 100, Cubatão, ROSEANE BARBOSA DA SILVA, qualificada a fls. 33, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, cocaína, maconha e "crack", causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 06/07 e auto de constatação preliminar de fls. 08/09. Segundo o apurado,

policiais militares, em patrulhamento, pelo local supramencionado, visualizaram a denunciada entregando algo para um indivíduo que, ao notar a presença das motocicletas dos milicianos, empreendeu fuga do local. Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram a denunciada e localizaram, em seu poder, uma nota de R\$ 20,00 e um "eppendorff" contendo cocaína. Indagada, a denunciada confessou, informalmente, a prática delitiva e indicou aos policiais o local onde teria guardado o restante das drogas. Realizadas buscas, os policiais encontraram, em um cano de água, próximo a denunciada, uma bolsinha, de cor rosa, contendo a quantia de R\$ 49,00, além de 41 "eppendorfs" contendo cocaína (55g – peso bruto, acrescido do pino localizado, em seu poder), 42 porções de maconha (90g – peso bruto) e 27 pedras de "crack" (5g – peso bruto). Ouvida formalmente, confessou a prática delitiva, acrescentando que estava vendendo drogas há aproximadamente duas semanas. Disse, por fim, que já esteve presa por crime de roubo, estando, atualmente, em livramento condicional (fls. 11/12). A razoável quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, os testemunhos dos policiais, demonstram que a denunciada praticava tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 104/108).

A acusada foi citada e apresentou defesa prévia (fls. 148). Juntada sua folha de antecedentes em fls. 45/47.

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, a ré foi interrogada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a aplicação de regime inicial diverso do fechado e a suspensão condicional da pena.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório da acusada.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria

SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), termo de depoimento (fls. 13/14), relatório final (fls. 96/99), laudo pericial (fls. 168-170), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição a ré, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciará.

Vejamos:

Em solo policial, o condutor e testemunha LUCAS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS disse que “O depoente informa que é Policial Militar, sendo que hoje acompanhado de seu colega de farda, realizavam o patrulhamento de rotina com motos pelo local dos fatos, quando tiveram a atenção voltada para a indiciada, que aparentemente servia algo a um indivíduo do sexo masculino, oportunidade em que o indivíduo ao perceber a aproximação das motocicletas correu na direção de uma escadaria, descendo e conseguindo êxito na fuga, enquanto a autora restou abordada, tendo em suas mãos uma nota de R\$ 20,00 reais e um ependorf de cocaína. Questionada pela equipe sobre os fatos, informalmente confessou que estava fazendo a mercancia das drogas, verbalizando que estava precisando de dinheiro, pois estava desempregada, apontando para a equipe onde o restante da droga estaria escondido, sendo localizado num cano de água próximo a ela uma bolsinha, de cor rosa, contendo em seu interior, a quantia de 49,00 (quarenta e nove reais) e farta quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), conforme consta no auto de exibição e apreensão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a indiciada, que foi conduzida para a Delegacia, onde foi revistada pela SdPM Ana, acionada para tal fim, nada sendo encontrado em seu poder, além dos mencionados nas mãos dela no ato da abordagem. A indiciada restou presa em flagrante. O material espúrio e o dinheiro restaram apreendidos em auto próprio” (fls. 13).

Em Juízo o policial militar reiterou a narrativa apresentada em solo policial. Disse que estava em patrulhamento com Elizângelo, pela cota 100, na Rua Seis, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Avistaram 2 indivíduos. Um deles era a Ré e o outro indivíduo, de sexo masculino, evadiu-se. A Ré ficou parada no local. Quando se aproximaram, em uma das mãos da Ré havia um pino de cocaína e uma quantia de R\$ 20,00. Indagada, a Ré confessou que estava realizando a mercancia das drogas. Indagada se havia mais drogas, a Ré afirmou que num cano de água havia uma bolsa contendo mais drogas. No local indicado encontrou uma bolsa rosa contendo as demais drogas. Foi acionada uma policial militar feminina para realizar busca pessoal na Ré, mas não encontraram mais nada. As drogas encontradas na bolsa rosa eram cocaína, crack e maconha, além de uma quantia em dinheiro (salvo engano R\$ 49,00). As drogas da bolsa já estavam embaladas como de costume para venda. A cocaína encontrada na bolsa era idêntica a encontrada na mão da Ré quando da abordagem. Em solo policial, a testemunha ELIZÂNGELO CALANDRIM SILVA ARAUJO disse que “Informa o depoente que é Policial Militar, sendo que hoje sua equipe realizava o

patrulhamento de rotina com motos pelo local dos fatos, quando teve a atenção voltada para a indiciada, que aparentemente servia algo a um indivíduo do sexo masculino, oportunidade em que o indivíduo ao perceber a aproximação das motocicletas correu na direção de uma escadaria, descendo e conseguindo êxito na fuga, enquanto a autora restou abordada, tendo em suas mãos uma nota de R\$ 20,00 reais e um ependorf de cocaína. Questionada pela equipe sobre os fatos, informalmente confessou que estava fazendo a mercancia das drogas, esclarecendo que estava precisando de dinheiro, pois estava desempregada, apontando para a equipe onde o restante da droga estaria escondido, sendo localizado num cano de água próximo a ela uma bolsinha, de cor rosa, contendo em seu interior, a quantia de 49,00 (quarenta e nove reais) e farta quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), conforme consta no auto de exibição e apreensão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a indiciada, que foi conduzida para a Delegacia, onde foi revistada pela SdPM Ana, acionada para tal fim, nada sendo encontrado em seu poder, além da droga e do dinheiro mencionados nas mãos dela no ato da abordagem. A indiciada restou presa em flagrante. O material espúrio e o dinheiro restaram apreendidos em auto próprio" (fls. 14).

Em Juízo reiterou a versão apresentada em solo policial e corroborou a narrativa já apresentada, sob o crivo do contraditório, por seu colega de farda.

Em solo policial, a acusada ROSEANE BARBOSA DA SILVA disse que "que estava na escadaria vendendo drogas quando foi surpreendida pelos policiais militares, os quais encontraram um pino de pó (cocaína) em seu poder e pediram para apontar onde estaria o restante da droga, afirmando que já tinham visto a venda acontecendo. Mostrei onde estavam o restante da droga, em um estojo escolar e me disseram que eu estava presa por tráfico. Está vendendo drogas há cerca de duas semanas pois está precisando de dinheiro para reformar sua casa, a qual foi destruída pelas chuvas. Que já esteve presa anteriormente por roubo e atualmente está em livramento condicional" (fls. 11/12).

Em Juízo confessou a prática do crime. Disse que os fatos aconteceram conforme a narrativa dos policiais.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que a ré praticou o crime descrito na denúncia.

A comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de

regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar a acusada – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente a acusada a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pela acusada. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de

Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que a acusada, de forma deliberada, guardava e tinha em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pela ré se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprido ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas uma das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de um patrulhamento perpetrado pelos agentes policiais.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas da acusada em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Adiante que, no caso em análise, é inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque o objetivo do aludido dispositivo de lei é privilegiar a figura comumente denominada por pequeno traficante ou traficante eventual, que pouco se dedica ao comércio espúrio e, quando o faz, realiza em pequena quantidade de drogas.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pela Ré. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento da Ré, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação da acusada por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, “não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, algumas circunstâncias que

deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: a grande quantidade de droga apreendida, 41 “eppendorfs” contendo cocaína (55g – peso bruto, acrescido do pino localizado, em seu poder), 42 porções de maconha (90g – peso bruto) e 27 pedras de “crack” (5g – peso bruto), autoriza uma maior reprovabilidade da conduta da ré, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, encontra-se presente a agravante da reincidência (processo nº 0005395-15.2021.8.26.0041 fls. 64). Também presente a atenuante da cofissão, que foi integral e espontânea. Dessa forma, com fulcro no art. 67 do CP, compenso-as integralmente, mantendo a reprimenda intermediária no patamar antes fixado (05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal)

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Ademais, não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencia à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio, além de ser reincidente, conforme asseverado supra.

Assim, estabeleço a pena final da ré em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, no mínimo legal.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica da acusada (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

De fato, malgrado a reincidência da acusada, realmente descabe a aplicação do privilégio contido no § 4º, do art. 33, como reiteradamente gizado, em razão da diversidade e significativa quantidade de entorpecentes apreendidos 41 “eppendorfs” contendo cocaína (55g – peso bruto, acrescido do pino localizado, em seu poder), 42 porções de maconha (90g – peso bruto) e 27 pedras de “crack” (5g – peso bruto).

Ora, o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 também deve ser interpretado em conjunto com o artigo 42 desta mesma lei especial.

Cedico que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL

RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Diante da reincidência da acusada, do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a" do Código Penal).

Ademais, o regime inicial deve ser o fechado, na hipótese dos autos, a despeito da extensão da pena carcerária aplicada, porquanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, atingiria um número considerável de usuários, como acima anotado, não autoriza a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, e ainda em virtude do quantum da pena corporal aplicada, a ré não faz jus à substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI – PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 14/15 e 86) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais.

O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência da acusada).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, de pois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ROSEANE BARBOSA DA SILVA, qualificado a fls. 33, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, mantenho a prisão preventiva da Ré e indefiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. A manutenção da prisão preventiva da ré se impõe pelo fato de ter permanecido presa durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, reforçados pelo título

condenatório.

Saliento que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória a sentenciada que respondeu ao processo preso preventivamente, precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública.

Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da sentenciada.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Assim, inexistindo prejuízos a sentenciada quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido (fls. 06/07) em decorrência de Tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito” (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Ante a manutenção da ré no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila “acompanhamento de preventiva decretada”, para eventual apreciação, se

os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome da Ré no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);
 - b) intímem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);
 - c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);
 - d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;
 - e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.
 - f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.
 - g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.
- Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).
- Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.
- Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA